

1500938-42.2021.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... que o réu teria admitido a prática do tráfico. Aduziu que foram encontrados apetrechos necessários para o preparo e venda da droga e que a diversidade da droga seria mais um indicativo do tráfico. Pugnou pela majoração da pena na primeira fase, em razão da diversidade das drogas apreendidas, bem como pelo reconhecimento, na segunda fase, da reincidência, aplicando-se o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500938-42.2021.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500938-42.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102385/2021 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 17341955 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 1506/21/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2102385 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSEIAS DE CAMPOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

OSEIAS DE CAMPOS e ANDRÉ FERREIRA DE LIMA foram denunciados como incurso nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, porque:

(I) desde data incerta até o dia 14 de abril de 2021, nesta Cidade e Comarca de Assis, associaram-se para praticar o crime de tráfico de drogas;

(II) em concretização à associação, no dia 14 de abril de 2021, por volta das 16:30h, na Rua Vereador José Siqueira da Silva, nº 130, área rural, na Cidade Florínea, nesta Comarca de Assis, traziam com eles, guardavam e tinham em depósito, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 2 pedras de crack, pesando 12,66g, 1 porção de maconha, pesando 4,03g e 1 porção de cocaína, pesando 1,72g.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais integrantes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes dirigiram-se até a residência situada na Rua Vereador José Siqueira da Silva, nº130, na cidade de Florínia, com o intuito de

darem cumprimento à mandado de buscas expedido pela 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Assis.

Chegando ao local, os policiais realizaram breve campana, ocasião em que notaram OSEIAS e ANDRE adentrando a residência. Assim, os policiais foram até o local, oportunidade em que avistaram OSEIAS e ANDRE ao fundo do corredor da casa.

Ao notar a aproximação dos policiais, rapidamente, OSEIAS arremessou um saco plástico na casa vizinha e tentou pular o muro, todavia, não obteve êxito.

ANDRÉ, por sua vez, notando a ação policial, tentou evadir-se do local, no entanto, também foi detido.

Os policiais, então, foram até a residência vizinha e localizaram a saco plástico arremessado por OSEIAS, dentro do qual havia porções de "crack".

Realizadas buscas na residência dos denunciados, foram localizados, na mesa da cozinha, um prato contendo uma lâmina "gillette", além de porções picadas de "crack", idênticas àquelas arremessadas por OSEIAS.

No balcão da cozinha também foi localizada certa quantidade de "maconha" e sobre a mesa foi encontrada uma porção de cocaína já embalada.

Realizada revista pessoal, em posse de ANDRE foi localizada a quantia de R\$ 164,00 e na mesa da residência foi localizada uma nota de R\$ 2,00 e algumas moedas.

Indagado informalmente sobre os fatos pelos policiais, OSEIAS disse que estava realizando o tráfico de drogas há 15 dias, mas nada quis dizer sobre ANDRE. Já ANDRÉ alegou que estava no local para comprar drogas de OSEIAS.

Os denunciados, então, foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia.

Desta forma, as informações recebidas pelos policiais, a quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e a conduta dos denunciados, típica de traficância, apontam que estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

O codenunciado ANDRÉ não foi encontrado para ser notificado, razão pela qual o feito foi desmembrado em relação a ele, tendo tramitado normalmente apenas em relação a OSEIAS.

O réu apresentou defesa prévia (fls. 214/217). Rejeitada esta, a denúncia foi recebida (fls. 280/281).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu.

As partes se manifestaram em alegações finais orais. O Ministério Público pugnou pela total procedência da ação penal, sustentando que a prisão do acusado se deu após realização de diligência de busca domiciliar, ocasião em que o réu teria admitido a prática do tráfico. Aduziu que foram encontrados apetrechos necessários para o preparo e venda da droga e que a diversidade da droga seria mais um indicativo do tráfico. Pugnou pela majoração da pena na primeira fase, em razão da diversidade das drogas apreendidas, bem como pelo reconhecimento, na segunda fase, da reincidência, aplicando-se o regime fechado.

A Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta. Afirmou que, em nenhum momento, OSEIAS admitiu estar traficando. Disse que os policiais afirmaram que realizaram campana e observaram a movimentação de várias pessoas, mas, em nenhum momento, apresentaram ou prendaram alguém que tivesse comprando droga. Os réus foram separados e em nenhum momento OSEIAS jogou as drogas pelo muro. A droga era para consumo. Pugnou pela aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, aplicação do regime aberto (HC 111.840) e justiça gratuita.

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls. 30/34) e pelos laudos toxicológicos (fls. 139/141 e 142/144), que testaram positivo para Cocaína e Tetrahydrocannabinol, substâncias catalogadas como drogas pela Portaria 344/98 da ANVISA.

A autoria restou igualmente demonstrada.

Nesse sentido, o policial Marcelo Maciel de Camargo informou que é integrante da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes e, na ocasião, havia recebido informação de que, em Florínea, OSEIAS e outro indivíduo de nome ANDRÉ estariam realizando o tráfico. Realizou contato com policiais de Florínea, os quais confirmaram que ambos realmente estariam realizando o tráfico. Então, fizeram

observação no local, onde foi possível verificar a entrada e saída de pessoas, típico de local de comercialização de entorpecentes. OSEIAS foi pesquisado, tendo sido constatado que ele já possuía passagem por tráfico. Então, houve representação por busca residencial. Na data dos fatos, dirigiram-se até o endereço autorizado para realização das buscas, tendo, de início, aguardado em campana próximo ao local. Em dado momento, visualizaram OSEIAS e ANDRÉ chegando na residência a pé. Após alguns minutos, foram cumprir o mandado de busca e, assim que entraram no imóvel, OSEIAS e ANDRÉ perceberam a entrada da polícia, tendo o primeiro arremessado uma sacolinha com droga na casa da vizinha e tentou pular o muro. Conseguiu conter OSEIAS, enquanto outro policial conteve ANDRÉ. Na casa da vizinha, localizaram sacolinha, a qual continha crack. Em buscas pela residência, encontraram na mesa da cozinha um prato e porções picadas de crack, além de uma porção de cocaína. No prato também tinha uma lâmina. No balcão da cozinha, encontrou uma porção de maconha. OSEIAS admitiu o tráfico informalmente, afirmando que havia iniciado a traficância há 15 dias e que iria "picar" o crack para vender, tendo comprado o crack por R\$ 200,00. ANDRÉ alegou que era usuário. Eles não estavam sob efeito de drogas. Anteriormente à autorização judicial de busca domiciliar, já havia feito campana no local, onde foram visualizadas pessoas entrando e saindo da casa. Com ANDRÉ só encontraram dinheiro, tendo ele dito que era usuário. Não conhecia ANDRÉ, mas conhece OSEIAS desde que ele era criança. Acabou conhecendo ANDRÉ através de campanas. Em nenhum momento OSEIAS disse ser usuário. Não sabe há quanto tempo OSEIAS morava no local. O endereço onde a diligência foi cumprida era a casa de OSEIAS.

O Leandro Isaac Pelegrini da Silva declarou que foi dar cumprimento ao mandado de busca domiciliar. Chegou a informação de que no endereço estava ocorrendo o tráfico. Não participou da campana, somente participou no dia do cumprimento do mandado. Foram até o local e visualizaram os dois chegando. Aguardaram um pouco para verificar se algum comprador chegaria no local, o que não ocorreu. Então, decidiram por dar cumprimento ao mandado de busca. Deram de frente com os dois, no corredor do imóvel. OSEIAS jogou uma sacolinha na direção da casa do vizinho e tentou pular o muro. Estavam em quatro policiais, tendo Marcelo abordado OSEIAS. ANDRÉ tentou sair "de fininho", razão pela qual o segurou. Informou à equipe que OSEIAS havia jogado uma sacola no vizinho, a qual foi posteriormente localizada. Entrou na residência e localizou prato com uma lâmina e resquícios de droga, aparentemente sendo crack. ANDRÉ disse que foi ao local comprar droga. Os dois estavam agitados. ANDRÉ aparentava estar um pouco alterado. Apenas conversou com ANDRÉ. Não conhecia ANDRÉ ou OSEIAS, mas a equipe conhecia. OSEIAS estava encostado no muro, de onde arremessou a droga. Não presenciou o encontro da sacola que foi jogada na vizinha.

Interrogado, o réu OSEIAS declarou que namorava a irmã do ANDRÉ há cerca de cinco meses. Trabalha fazendo bicos. Morava sozinho há cerca de três meses, no local dos fatos. Já foi condenado por tráfico. Negou os fatos, asseverando que a droga localizada em sua residência era para seu uso. Usa três tipos de droga, sendo maconha, cocaína e crack. Tinha acabado de cheirar pó. ANDRÉ também morava em Florínea e usava droga consigo. Na ocasião, tinha acabado de chegar em casa com ANDRÉ para usarem droga. Entrou em casa e a polícia chegou logo após apontando a arma. Ficou paralisado, não teve reação. Não jogou droga no quintal do vizinho, a droga foi localizada em seu bolso. Pagou R\$ 5,00 na maconha e R\$ 200,00 no crack. Não se recorda quanto pagou na cocaína. Às vezes chamava os amigos para irem à sua casa usarem droga. Não vendia droga, apenas usava. Não sabe dizer exatamente quanto recebia por semana ou mês, pois depende do serviço. Pra limpar quintal, cobrava de R\$ 50,00 a R\$ 60,00 por dia. Para colher batata, recebia um pouco mais. Na época dos fatos, trabalhou bastante, mas não se recorda quanto recebeu no mês. Pagava aluguel na casa em que morava, sendo R\$ 200,00 por mês. Não tem mais notícia de ANDRÉ. Usava cocaína e crack para ficar agitado e maconha para se acalmar. Não falou ao policial que estava vendendo droga, disse que era usuário. Quando os policiais entraram na casa, estava na porta da sala junto com ANDRÉ. Em nenhum momento tentou pular o muro. Sobre o ANDRÉ não sabe dizer, pois os policiais os separaram. Somente depois soube que ANDRÉ tinha dinheiro. ANDRÉ já tinha ido em sua

casa outras vezes para usar drogas. Está preso há 1 ano e 3 meses. A droga que foi apreendida em sua casa foi comprada no mesmo dia. No dia de sua abordagem, estava na posse de seu celular, tendo os policiais pedido para liberar a senha do aparelho. Obedeceu a ordem, mas os policiais não apreenderam o aparelho. Pois bem. As provas produzidas nos autos autorizam um decreto condenatório. De fato, os depoimentos dos policiais foram seguros e coesos, os quais, vale destacar, gozam da credibilidade ordinária, à semelhança do que ocorre em relação a outras testemunhas. A propósito:

A circunstância de ser policial a testemunha não afeta positiva ou negativamente o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados. (TJSP, Ap. n.º 0015805-56.2011.8.26.0309, 9ª Cam. Dir. Criminal, Des. Souza Nery, D.j. 17.05.12, D.r. 19.05.12).

Ademais, a versão do réu no sentido de que as drogas apreendidas se destinariam ao próprio consumo restou isolada nos autos.

De acordo com o art. 28, §2º, da Lei 11.343/06, "Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso em tela, como visto, apesar de não ser vultosa a quantidade de droga localizada em poder do réu, certo é que a diversidade de entorpecentes apreendidos em sua posse, por si só, afasta a alegação de destinação ao consumo próprio. Além disso, conforme exposto pelos policiais, o acusado, ao perceber a presença dos agentes públicos, arremessou uma sacola contendo crack na casa da vizinha e, na sequência, tentou se evadir pulando o muro, conduta própria de quem quer disfarçar a prática de ilicitudes, incompatível com o mero consumo de entorpecentes. Inclusive, verifica-se à fl. 20 que OSEIAS asseverou em sede policial que "arremessou a droga porque estava muito louco e não sabia o que faria", ao passo que, em juízo, disse não tê-lo feito. Tal contradição, além de gerar dúvidas acerca da real conduta do réu no momento da abordagem, não infirma a versão apresentada pelos policiais.

Ademais, verifica-se dos autos que a apreensão das drogas foi decorrente de mandado de busca, obtido após informações de que o acusado estava praticando o tráfico, o que se confirmou com a localização dos três tipos diversos de entorpecentes, além de objetos (prato e lâmina) que continham resquícios de cocaína (laudo às fls. 142/144).

Por tudo isso, considero forçoso o reconhecimento de que a conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e não ao art. 28, caput, da mesma Lei.

Anote-se, por oportuno, que a condição de usuário não é incompatível com o tráfico de drogas, aliás não raramente a prática do tráfico ocorre para garantir o custeio do uso de drogas.

Relevante destacar, ademais, que a configuração do tipo penal em questão prescinde da demonstração do comércio, porquanto se trata de tipo de conduta múltipla e se perfaz não apenas com o comportamento vender, mas também com vários outros, inclusive trazer consigo, guardar e ter em depósito, como ocorreu na espécie.

Portanto, a dinâmica dos fatos permite concluir que a droga se destinava à traficância, razão pela qual o acolhimento da pretensão é medida de rigor.

Entretanto, não prospera o tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006.

Isso porque, não há provas de que OSEIAS e ANDRÉ se uniram de maneira estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo elementos para se concluir que a situação se apartara de mero concurso de agentes, pseudo-concurso, insuscetível de configuração de crime autônomo. Não basta que duas ou mais pessoas pratiquem juntas o tráfico de drogas para incidirem em tipo autônomo, na medida em que o núcleo do tipo é associarem-se, que denota, por sua semântica, os elementos da estabilidade e permanência, imprescindíveis à tipicidade formal. Portanto, apenas o ajuste entre dois ou mais indivíduos que se estabiliza é que permite a incidência do art. 35, ainda que as tratativas duradoras sejam para a

prática de um único crime de tráfico de drogas; motivo pelo qual a lei vale-se da expressão "reiteradamente ou não". Nesta direção, e.g, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. II De outro lado, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/06 (REsp. 1.113.728/SC, Min. Rel. Felix Fischer, 5ª T., j. 29.09.2009) (destaquei).

Destarte, impõe-se o desacolhimento da pretensão, nesse particular.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, não se prestando a tanto a natureza ou a diversidade da droga, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Por outro lado, verifica-se que o sentenciado é reincidente [processo 0012164-65.2014.8.26.0047 (tráfico) – fl. 318], razão pela qual entendo adequada a majoração da reprimenda em 1/5, fixando a pena intermediária em 6 anos meses de reclusão, além de 600 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena, não se aplicando o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 tendo em vista tratar-se de sentenciado que ostenta reincidência específica. Portanto, torno definitiva a pena de 6 anos de reclusão, além de 600 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu OSEIAS DE CAMPOS, ao cumprimento de 6 anos de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Regime inicial de cumprimento de pena: Como cediço, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017). Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena não mais será obrigatoriamente o fechado, devendo ser fixado tendo em consideração o parâmetro contido no art. 33, 2º, alíneas "a" a "c" c.C § 3º do mesmo artigo.

Diante disso, em que pese a pena fixada ao sentenciado não ser superior a 8 (oito) anos de reclusão, certo é que ele é reincidente, de sorte que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

Substituição por pena restritiva de direitos: Incabível. Não mais subsiste a vedação legal, uma vez que, após o Supremo Tribunal Federal, em controle concreto, declarar a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas, o Senado Federal editou a Resolução nº 5/2012, que suspendeu a execução de tal disposição legal. Logo, a verificação do cabimento ou não da substituição, deverá realizar-se segundo as peculiaridades do caso concreto, seguindo-se as diretrizes contidas nos artigos art. 44 e seguintes do do Código Penal.

No caso em tela, considerando-se que a pena fixada ao sentenciado é superior a 4 anos de reclusão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Suspensão condicional da pena: incabível também em razão da quantidade de pena aplicada.

Prisão preventiva: de rigor sua manutenção, uma vez que agora, pelo menos para o juízo de primeiro grau, não há apenas probabilidade do crime e da respectiva autoria, mas certeza. Ademais, subsistem os fundamentos que determinaram sua decretação, persistindo a necessidade da prisão para fim de garantia da ordem pública.

Da destinação dos bens apreendidos:

Determino a destruição dos objetos apreendidos (prato e lâmina), bem como da droga. Saliente-se que a destinação da quantia apreendida será realizada na ação penal que apura a conduta de ANDRÉ, porquanto o dinheiro foi apreendido com ele.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intime-se o sentenciado para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020.

Por fim, dispense o réu do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC. Arbitre os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio.

Expeça-se certidão.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA